

1500958-97.2022.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500958-97.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500958-97.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2111518/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 24519201 - DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ VITOR DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

JOSÉ VITOR DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA e MATEUS AMARO CORRÊA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, porque, em data incerta, mas anterior ao dia 25 de abril de 2022, em local incerto, mas nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim de traficarem drogas.

Consta ainda que, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 23h00min., na Rua Mirabeau Camargo Pacheco, n.º 597, Parque Santa Inês, nesta cidade e comarca, os réus traziam consigo, para a entrega ao consumo de terceiras pessoas, 63 (sessenta e três) porções de cocaína em forma de "crack", pesando 13,56g; 51 (cinquenta e uma) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido aproximado de 60,28g, e 80 (oitenta) porções de cocaína, pesando 7,11g,

drogas estas que determinam dependência física ou psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, laudo de constatação provisória de fls. 77/83 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 64/67, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fls. 94/95), os réus foram pessoalmente citados (fls. 132 e 134) e ofertaram resposta a acusação (fls. 105/114 e 140/141). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 176/177) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas da acusação presentes e realizado o interrogatório dos acusados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, por meio de alegações finais (fls. 199/204), pugnou pela parcial procedência da ação penal, com consequente condenação dos acusados pela infração prevista nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal.

A defesa de José Vitor (fls. 208/215), por meio de alegações finais, pleiteou a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu pelo reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do Código Penal, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A defesa de Mateus, por sua vez, em alegações finais (fls. 216/219) requereu pela absolvição do acusado, pela insuficiência probatória em relação a autoria. Em caso de condenação, requer pelo reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que procede parcialmente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que a materialidade dos delitos veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), laudo de constatação provisória (fls. 22/24), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 64/67) e prova oral produzida.

A autoria em relação ao tráfico de drogas está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Carlos Alberto Nepomuceno, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pela Vila Jardim, quando receberam notícia de que havia dois indivíduos na prática de tráfico no pátio dos prédios, com informações sobre a roupa que estariam usando e o local correto em que estavam traficando. Se dirigiram até o local e encontraram os indivíduos com as características mencionadas, os quais empreenderam fuga para o interior dos prédios ao avistarem os policiais. Conseguiram deter ambos. Eles tentaram entrar cada um deles em um apartamento, um ao lado do outro, mas foram abordados. Abordou José Vitor e, na blusa dele, havia R\$ 534,00 em dinheiro e 57 porções de crack, e em nos shorts, um aparelho celular. O soldado Moraes abordou Mateus, que portava uma pochete, em cujo interior havia 51 porções de maconha, 80 porções de cocaína e 6 porções de crack. Que ambos confessaram a prática de tráfico no local. Nunca havia abordado os dois réus e não tem informações de uma associação estável para o tráfico entre eles.

A testemunha arrolada pela acusação David Aparecido Zorzato Júnior, policial militar, confirmou o depoimento do PM Nepomuceno, acrescentando que estava presente uma das características da associação para o tráfico, que é a distribuição de funções, um deles recebe o dinheiro e o outro faz entrega a droga. Que José estava com a quantia maior em dinheiro e menor quantidade de drogas.

O acusado José Vitor dos Santos Gonçalves da Silva, inquirido na esfera administrativa, guardou silêncio. Em juízo, negou os fatos a si imputados. Relatou que estava em seu apartamento com sua tia, a porta estava aberta, por isso viu que policiais subiram e entraram no apartamento ao lado. Em seguida, esses policiais vieram ao seu apartamento, respondeu aos policiais que não havia nada de ilícito no apartamento. Os policiais perguntaram se poderiam entrar e, com a sua permissão e de sua tia, eles o fizeram. Revistaram o local e não encontraram nada de ilícito. Viu Mateus, a quem não conhecia, apenas quando foi colocado na viatura, também não

conhecia os policiais que o prenderam.

O acusado Mateus Amaro Corrêa, inquirido na esfera administrativa, guardou silêncio. Em juízo, negou os fatos a si imputados. Relatou que estava na quadra, jogando bola, no dia de sua prisão, no prédio onde mora seu primo. Quando estava voltando para o apartamento do primo, subindo as escadas, escutou que os policiais estavam entrando. Foi até o apartamento do primo, e quando ele fechou a porta, os policiais entraram no apartamento. Não sabe onde os policiais encontraram droga, eles apareceram com drogas dizendo que eram suas, sendo que nem mora naquele local. O primo não estava em casa naquele momento. Não conhece José Vitor e os policiais. À luz da prova oral supra transcrita, tem-se a presença de elementos de cognição suficientes para sustentar que o decreto condenatório seja prolatado com a segurança e certeza necessária e exigíveis. Os elementos probatórios presentes nos autos levam a conclusão de que os acusados são os autores do delito de tráfico. Em que pese as negativas dos acusados, alegando que desconhecem de onde os policiais tiraram a droga apreendida, a mesma não convence, mostrando-se isolada nos autos. O relato das testemunhas, sob a égide do contraditório e ampla defesa, prestados com detalhes e de forma harmoniosa, são bastante convincentes e indicam a ocorrência da apreensão da droga e traficância descritas na denúncia.

Ademais, não se logrou demonstrar que as autoridades policiais, ouvidas sob o crivo do contraditório, eventualmente foram parciais, ou nutriram interesse em prejudicar o acusado, de modo que os seus testemunhos se mostram imaculados e, por isso, constituem meio idôneo de prova. Assim, não há qualquer motivo para desacreditar das autoridades policiais ouvidas em juízo, vez que compromissadas e sujeitas às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

No tocante à finalidade com que os réus guardavam as substâncias entorpecentes, tendo em vista que as drogas estavam acondicionadas da forma como costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo pericial, fica claro o objetivo de mercancia.

Nesse sentido:

“Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível.” (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273)

Destaca-se, ainda, que a ausência de visualização de atos de mercancia não afasta a ocorrência do tráfico, pois a simples ação de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

Apelação- Tráfico de drogas- Condenação- Recurso defensivo -Pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal- Não acolhimento- Materialidade e autoria comprovadas -Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade- Prova oral harmônica e coesa- Apelante que transportava droga perniciosa (cocaína), em quantidade elevada (25,6 gramas de massa líquida -suficientes para produzir cerca de 100 porções individuais) e acondicionada em embalagem típica de mercancia- Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância- Tentativa de fuga do agente ao perceber a presença da viatura- Versão do sentenciado inverossímil e dissociada das provas coligidas- Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia -Crime de ação múltipla ou conteúdo variado- Bastante comum a figura do "traficante-usuário" ou "usuário-traficante"- Pedido de aplicação da pena no mínimo legal- Acolhimento parcial- Desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 2/5, a despeito da quantidade de droga -Redução para 1/6- Parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça- Na segunda fase da dosimetria, o incremento em 1/3 teve fundamento idôneo -Reincidência específica- Precedentes- Revisadas as penas definitivas- Manutenção do regime inicial fechado- Recurso parcialmente provido (TJSP - Apelação Criminal 1500148-22.2018.8.26.0578, Relator(a): Juscelino Batista, Comarca: Ourinhos, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 09/03/2021, Data de publicação:09/03/2021).

Com efeito, a prática de tráfico de drogas foi confirmada pela apreensão de drogas em posse dos acusados, quais sejam, 57 porções de crack em posse de José Vitor e 51, porções de maconha, 80 de cocaína e 6 de crack em posse de Matheus. Cumpre ainda destacar que também houve apreensão, no mesmo contexto fático, de certa quantia em dinheiro em poder do réu José Vitor (R\$ 534,00), não sendo comprovada sua origem.

A forma como se deu a abordagem dos acusados e a apreensão das drogas restaram devidamente apuradas diante da narrativa trazida pelos policiais que efetuarão a prisão em flagrante.

A dúvida razoável, na lição de Renato Brasileiro (in Manual de Processo Penal, 2021, p. 563), é a dúvida baseada na razão e no senso comum, é a dúvida que uma pessoa razoável possui, após sopesar as provas, que a leva a hesitar a tomar uma decisão. Não é especulação ou suspeita, não é compaixão. No caso em apreço a análise dos elementos probatórios não deixa espaço para qualquer dúvida razoável, portanto, inaplicável ao caso o in dubio pro reo, restando tipificada ambas a materialidade e autoria.

Com efeito, diante de todo o conjunto probatório, suficiente concluir que as drogas descritas na denúncia pertenciam aos réus e eram, sem sombra de dúvida, destinadas à traficância. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois nada impede que o traficante seja, ao mesmo tempo, usuário dos entorpecentes.

Contudo, quanto ao crime de associação para o tráfico a absolvição se impõe, pois não restou comprovado que os réus mantivessem uma associação estável, requisito necessário para a caracterização do crime.

Nesse sentido:

"Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei nº 1.343/2006. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual)"(STJ. HC 139.942/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 19.11.2012, noticiado no Informativo 509).

Demonstrada a ocorrência do crime do artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência em parte da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Passo a analisar a pena de ambos os réus por sustentarem situação análoga.

Na primeira fase, atendendo as circunstâncias judiciais do previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 59, do Código Penal, depreende-se que os réus não possuem antecedentes (fls. 38/46), nem demais circunstâncias negativas a serem consideradas. Entretanto, considerando a grande quantidade de drogas, aumento a pena-base em 1/6 e início em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da menoridade, de modo que retorno a pena ao mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação de pena, deixo de considerar o tráfico privilegiado. Referida causa de diminuição de pena tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida.

Neste particular, há que se ressaltar o fato de os réus ostentarem passagens pela Infância e Juventude, como se vê às fls. 40 e 43, ou seja, o crime não era fato isolado em sua vida, tal circunstância indica que eles eram dados à prática de ilícitos, inclusive tráfico de drogas.

Frise-se que a conduta ilícita praticada quando menores, neste caso, não foi usada a título de Maus Antecedentes ou reincidência, mas sim como um reforço à constatação do envolvimento com atividades criminosas. Nesse sentido, tem decidido o C.STJ:

“Esta Corte é uníssona no sentido de que atos infracionais anteriores não podem ser sopesados na apuração de Maus Antecedentes para elevar a pena base, tampouco para induzir a reincidência, entretanto, tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas.

Precedentes. 4. Desde que devidamente comprovado, o envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas” (HC 299.673/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/08/2016).

De igual forma, a razoável quantidade da droga indica não se tratar de traficante ocasional.

Ademais, a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar aqueles infratores que agiram ocasionalmente, o que não representa o caso dos autos.

Nesse sentido é o posicionamento do E.TJ/SP, no seguinte julgado: “Lei de Tóxicos (nº 11.343/06). Tráfico. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio.

Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio.

Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa.

Apenamento impassível de abrandamento. Fixação da pena-base no mínimo legal, diante da aplicação dos critérios explicitados em determinação do C. S.T.J.

Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo improvido.” (Apelação nº 0022448-60.2013.8.26.0050, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, j. 29/01/2019).

Diante das circunstâncias subjetivas desfavoráveis acima elencadas, especialmente as circunstâncias da prisão, a razoável quantidade da droga, e ainda, o fato de ostentar o acusado envolvimento anteriores na Vara da Infância e Juventude, entendo que o único regime capaz de reeducar e frear a conduta criminosa do réu é o inicial fechado. Regime menos severo seria insuficiente para a correta repressão do delito praticado.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados JOSÉ VITOR DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA e MATEUS AMARO CORRÊA, qualificados nos autos, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 500

dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e ABSOLVE-LOS da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação do "sursis", em razão de não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Os réus, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderão apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-os na prisão em que se encontram, com as cautelas de praxe.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º, do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA